

1500175-75.2022.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... 209/210). No mesmo sentido a jurisprudência: "TRAFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da droga, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olimpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500175-75.2022.8.26.0574 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500175-75.2022.8.26.0574

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152227/2022 -

DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 25380068 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2152227 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2152227 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON CARLOS GONÇALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

WELLINGTON CARLOS GONÇALVES e LYELTON DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 35, caput, e artigo 33, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, sob a acusação de que no dia 04 de junho de 2022, por volta das 17h30min, e, em datas anteriores e lugares incertos, mas também em imóvel situado na Rua Brasilino de Freitas Negrão, nº 239, Parque Nove de Julho, nesta cidade e comarca de Cerqueira César/SP, associaram-se entre si para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, inclusive o

descrito abaixo.

Consta, também, que no dia 04 de junho de 2022, por volta das 17h30min, em imóvel situado na Rua Brasilino de Freitas Negrão nº 239, Parque Nove de Julho, nesta cidade e comarca de Cerqueira César/SP, os denunciados traziam consigo, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam, 06 (seis) porções/pedras de Cocaína ("crack"), com peso bruto de 42,97 gramas (quarenta e dois gramas e quarenta e sete decigramas), substância que causa dependência, o que faziam em desacordo com norma legal ou regulamentar, (portaria 344/98SVS/MS), para fins de consumo de terceiros (cf. Auto de exibição e apreensão de fl.09, auto de constatação provisória a fls. 11/14, laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 226/228 e fotografias de fls. 95/96).

Auto de prisão em flagrante delito e demais peças do inquérito policial (fls. 01/118). Em audiência de custódia realizada em 05 de junho de 2022, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos réus (fls.166/170). Mandados de prisão cumpridos (fls. 184/187). Notificados (fls.277 e 279), o réu Wellington apresentou defesa preliminar (fls.259/261). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em relação ao réu Wellington em 25 de julho de 2022 (fls. 269). O réu Lyelton ofereceu defesa prévia (fls. 284/285), não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em relação ao réu Lyelton em oportunidade em 02 de setembro de 2022, ocasião em que também houve a designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 287/289). Em audiência, foram inquiridas uma testemunha de acusação, uma testemunha em comum, uma testemunha de Defesa e os réus foram interrogados (fls.327/329-gravações audiovisuais).

Em alegações finais, o Ministério Público discorreu sobre toda a prova produzida e pugnou pela procedência da ação para condenar os réus nos exatos termos da denúncia (fls.327/328). Por sua vez, a douta defesa do réu Lyelton pugnou pela absolvição do réu por fragilidade probatória (fls.330/333). Já a douta defesa do réu Wellington requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso IV, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 354/360).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e Decido.

Segundo a inicial acusatória, " nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados associaram-se entre si, de forma estável e permanente,para a prática do crime de tráfico de drogas na Comarca de Cerqueira César/SP. Assim é que, no dia 04 de Junho de 2022, por volta das 17h30min., no local acima descrito, os denunciados traziam consigo, vendiam,entregavam a consumo e forneciam, 06 (seis) pedras de Cocaína ("Crack"), com peso bruto de 42,97 gramas (quarenta e dois gramas e noventa e sete centigramas),substância que causa dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de consumo de terceiros, quando foram surpreendidos por policiais militares.Conforme se infere dos autos, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram os denunciados, que ao se depararem com a viatura, empreenderam em fuga e adentraram em imóvel de um terceiro, posteriormente identificado e qualificado como WAGNER ALESSANDRE NOVAGA ALVES.Ato contínuo, realizada a abordagem, foi constatado que o denunciado WELLINGTON trazia consigo a quantia de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) e um aparelho celular e o denunciado LYELTON trazia consigo a quantia de R\$1500,00 (cento e cinquenta reais) e 06 (seis) pedras de Cocaína ("Crack"), com peso bruto de 42,97 gramas (quarenta e dois gramas e noventa e sete centigramas), substância que causa dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de consumo de terceiros. Assim, associados entre si para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, os denunciados traziam consigo, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas.Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados e estes foram conduzidos ao plantão policial de Avaré/SP.Anote-se que a natureza da droga, a atuação conjunta de ambos os denunciados na prática dos delitos e as demais particularidades do caso, nos termos do artigo 28, §2º, da

Lei nº 11.343/06, verifica-se que a droga apreendida se destinava efetivamente ao consumo de terceiros, bem como que eles estavam associados para a execução desta empreitada."

Pois bem, ao ver deste juízo, a ação penal merece ser julgada procedente em parte. A materialidade do delito de tráfico de drogas restou configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), pelo boletim de ocorrência de (fls. 05/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo de constatação provisória (fls. 11/12), pelo laudo toxicológico (fls. 226/228), bem como por toda prova oral produzida.

A autoria do crime de tráfico de drogas também restou comprovada e repousa, sem sombras de dúvidas, sobre os réus.

A testemunha de acusação Uassir Dognani Junior, policial militar, em juízo, "disse que efetuavam diligência no local dos fatos, momento em que visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, os quais ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram se evadir e adentraram na residência de Wagner. Realizaram a abordagem e em revista pessoal com Wellington foi encontrado a quantia de R\$380,00 e um aparelho celular e com Lyelton localizaram R\$150,00 e 06 pedras de crack. Disse que Lyelton admitiu ser traficante e que Wellington falou que somente estava acompanhando Lyelton."

A testemunha em comum Wagner Alessandro Novaga " relatou que o Wellington é serralheiro e estava fazendo um orçamento em sua casa. Afirmou que o familiar dele que iria pagar o serviço. Afirmou que é usuário de drogas. Disse que os dois réus estavam em sua residência na hora da abordagem policial. Relatou que foi sua irmã que contratou o serviço deles. Afirmou que é usuário de crack por aproximadamente 10 anos. Negou o depoimento prestado em solo policial, afirmando que não falou para o Delegado os fatos ali narrados."

A testemunha de Defesa Márcio José Nogueira " relatou que conhece Wellington porque já utilizou seus serviços como serralheiro. Afirmou ser pessoa honesta e trabalhadora".

O réu Wellington Carlos Gonçalves " disse que na data dos fatos, a polícia os abordou dentro da casa de Wagner. Relatou que perguntaram o que tinha com ele, disse que tinha dinheiro e celular. Realizaram a revista pessoal e foi conduzido até a Delegacia como testemunha. Contou que foi até a casa de Wagner para fazer um orçamento de um portão, a pedido deste. Disse que Lyelton estava na casa do cunhado dele, o Cleber, local onde o conheceu. Relatou que Lyelton que quis ir junto com ele à casa de Wagner. "

Interrogado o réu Lyelton de Oliveira negou a prática delitiva. " Disse que mora em Macatuba e que veio para Cerqueira César para uma festa de aniversário de um familiar de sua esposa. Chegando na casa dos parentes, conheceu Wellington , que trabalhava como serralheiro, e este o convidou para ir fazer um orçamento de um portão na casa de Wagner. Foram até a residência dele e entraram. Wagner estava conversando com o Wellington sobre o serviço, momento em que a Polícia entrou , fizeram a abordagem e o levaram até a Delegacia, porque ele já tinha passagem pela polícia. Relatou que o dinheiro e as drogas não eram de sua propriedade. Não sabe de quem era a droga e o dinheiro."

Pois bem, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observo que a negativa dos réus não encontram amparo nas demais provas do feito, sendo de rigor a condenação.

Nesse contexto, a versão dos réus, além de inconsistente e implausível de per si, permaneceram de todo isoladas no contexto probatório, já que eles nada produziram, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, enquanto os depoimentos reproduzidos sob o contraditório encerraram-se convergentes e coesos à confirmação do fato imputado, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação.

In casu, a tipificação do crime de tráfico de drogas extrai-se das circunstâncias da prisão, do modo pelo qual estava acondicionada a droga- em porções individuais a facilitar a comercialização e disseminação da droga, bem como do dinheiro localizado, cuja origem lícita os réus não comprovaram nos autos.

Assim, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu confirmaram os termos da inicial acusatória e evidenciaram sua responsabilidade criminal. Por isso, força convir que seus depoimentos merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os seus depoimentos prestados extrajudicialmente.

Destarte, os elementos probatórios coligidos estão a revelar iniludível traficância. Não se vislumbra qualquer interesse dos policiais em acusar ou prejudicar o réu, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra pessoa (CPP, art. 202), prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho que, como visto, não tinham razão para incriminá-lo, graciosamente, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, art. 214). Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos investigadores, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou em faltarem com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido:

"A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifo nosso)"

Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ademais, as drogas foram encontradas em pequenas porções, forma de acondicionamento própria da venda "a varejo" de entorpecentes, restando devidamente demonstrada a finalidade comercial das drogas.

De mais a mais, ressalto que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

Por derradeiro, é o fato de que os réus em nenhum momento comprovaram satisfatoriamente exercer atividade lícita/emprego, portanto não teria dinheiro para adquirir as drogas, algo que também indica seu envolvimento com a criminalidade organizada.

Além disso, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação e/ou perseguição. Não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução.

Por outro lado, em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei de Drogas), observo que não há prova acerca do suposto "animus" associativo entre os réus. Tal qual o crime do artigo 288 do Código Penal, a associação para a traficância demanda elo perene e estruturado entre agentes para a prática do crime. É delito autônomo e dispensa até a prova do tráfico, suficiente a finalidade da associação.

Porém, inadmissível que toda e qualquer comparsaria, quando provada, aponte objetivamente a responsabilidade por tal delito autônomo, sendo imprescindível a prova da perene associação entre os sujeitos, com a finalidade específica da traficância.

Assim, o crime de associação somente se caracteriza quando ocorre estabilidade e permanência entre os agentes. E sem a prova efetiva de uma verdadeira associação permanente e duradoura voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, não há como sustentar um decreto condenatório.

As provas produzidas limitam-se apenas a um depoimento genérico do policial, não havendo qualquer outro elemento acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo tal como conversas de telefone, troca de mensagens, caderno de anotações etc.

Nesse sentido vem ensinando a doutrina: "não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria" (Tóxicos, Vicente Greco Filho, Editora Saraiva, 14ª edição, pág. 209/210). No mesmo sentido a jurisprudência: "TRAFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da droga, razão pela qual a simples alegação de ser usuário não basta, por si só, para operar a pretendida desclassificação, mormente quando isolada do conjunto probatório, incumbindo ao réu provar que a substância se destinava para exclusivo consumo pessoal. O crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não se configura diante de uma associação meramente eventual, mas apenas quando ela for estável e duradoura, ligada pelo animus associativo dos agentes, formando uma verdadeira *societas sceleris* que não se confunde com a simples co-autoria. Não tendo restado caracterizado que a associação era reiterada, a conduta deve ser considerada mais como uma consequência da ação única que deu origem ao tipo principal que é o tráfico de substância entorpecente. (TJ-PR - ACR: 4866746 PR 0486674-6, Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 18/09/2008, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7743)." Por essa razão a absolvição do crime de associação ao tráfico é medida que se impõe.

Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que os réus praticavam o comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os réus WELLINGTON CARLOS GONÇALVES e LYELTON DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Por outro lado, ABSOLVO os réus do crime que lhe foi imputado na denúncia tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Em relação ao réu Wellington Carlos Gonçalves na primeira fase, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, bem como aos antecedentes do réu (F.A. e certidões a fls. 123/127), fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (certidão - fls.123). Portanto, majoro em 1/6 a pena anteriormente aplicada, fixando em 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. Na terceira fase, muito embora não exista nenhuma notícia e mesmo prova nos autos de que o réu pertencia a alguma associação criminosa, entendo que a condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (fls.123), revela a conduta voltada à prática de atividades criminosas. Ademais, a prova dos autos indica que fazia o tráfico com certa frequência e de droga de fácil disseminação e com alto poder de vício ("crack"). Tal circunstância impede a aplicação do benefício legal do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas. Nesse sentido: "Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante por tráfico

de drogas. Liberdade Provisória: inadmissibilidade. Decisão que manteve a prisão. Participação em organização voltada para o tráfico de entorpecentes e grande quantidade de droga apreendida: circunstâncias suficientes para a manutenção da custódia cautelar. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06 e de substituição da pena: improcedência. Redução da pena inviável na via estreita do habeas corpus. Ordem denegada. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12 – destaquei do original). Sendo assim, fixo em definitivo a pena a cumprir de 05 (CINCO) E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL. Em relação ao réu Lyelton de Oliveira na primeira fase, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, bem como aos antecedentes do réu (F.A. e certidões a fls. 128/131 e 133/142), fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (certidão -fls. 128). Portanto, majoro em 1/6 a pena anteriormente aplicada, fixando em 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. Na terceira fase, muito embora não exista nenhuma notícia e mesmo prova nos autos de que o réu pertencia a alguma associação criminosa, entendo que a condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (fls.128), revela a conduta voltada à prática de atividades criminosas. Ademais, a prova dos autos indica que fazia o tráfico com certa frequência e de droga de fácil disseminação e com alto poder de vício ("crack"). Tal circunstância impede a aplicação do benefício legal do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas. Nesse sentido: "Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante por tráfico de drogas. Liberdade Provisória: inadmissibilidade. Decisão que manteve a prisão. Participação em organização voltada para o tráfico de entorpecentes e grande quantidade de droga apreendida: circunstâncias suficientes para a manutenção da custódia cautelar. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06 e de substituição da pena: improcedência. Redução da pena inviável na via estreita do habeas corpus. Ordem denegada. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12 – destaquei do original). Sendo assim, fixo em definitivo a pena a cumprir de 05 (CINCO) E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

A pena imposta aos réus deverá ter seu início de cumprimento em regime FECHADO. Apesar de o STF já ter decidido, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da regra que determina a obrigatoriedade de adoção de regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (Lei 8.072/90, art. 2º, §1º), o citado precedente não concluiu, por outro lado, pela imposição indiscriminada de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena em tais delitos. Ao contrário. Ainda que, de fato, não possa a lei vedar, aprioristicamente, a adoção de um regime inicial diverso do fechado, mesmo para os crimes hediondos e equiparados, o STF permitiu a adoção de regime inicial mais severo quando presentes elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59 do Código Penal (cf. HC 111.840, Rel. Min.

Dias Toffoli, DJe 17/12/2013). O caso dos autos, no qual se constatou a prática de tráfico de considerável quantidade de entorpecente, demanda a adoção de regime prisional mais severo, sob pena de se produzir, como efeito colateral de um arrefecimento despropositado da reprimenda estatal, uma sensação de impunidade àqueles que demonstram desprezo à manutenção da ordem pública. É importante não perder de vista que a consideração do tempo de prisão provisória da ré não altera o panorama do regime inicial da pena aplicada. Assim, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois como bem indica Guilherme de Souza Nucci, "O disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento" ("Código de Processo Penal Comentado", 13ª edição, Editora Forense, páginas 805 e 806). Desta forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciosos para decidi-la.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta interiorana cidade de Cerqueira César.

Deixo de reconhecer o direito dos réus de apelarem em liberdade, em observância ao artigo 312 do CPP c.c. artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90, pois a gravidade do delito, que vem se alastrando de forma avassaladora também nas pequenas cidades, torna evidente a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública. Outrossim, porque os réus responderam presos ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-los em liberdade exatamente depois de receber sentença condenatória. Recomendem-se.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração

suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado. Havendo indícios do cometimento do crime de falso testemunho por Wagner Alessandro Novaga Alves (artigo 342 , caput, do Código Penal), oficie-se ao Ministério Público, com cópias das peças pertinentes, para as providências cabíveis. Registre-se, desde logo, que, em caso de recebimento de eventual recurso de apelação interposto contra a presente, deverá serem expedidas as competentes guias de execução provisória em nome dos réus/condenados recorrentes, nos termos do que dispõe o art. 9 da Resolução nº 113/2010 – CNJ, para que possa, quando for o caso, obter os benefícios previstos na LEP (sumula do STF, Enunciado nº 716). Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) do condenado; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações, com as devidas identificações, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei. P.I.C.

Cerqueira Cesar, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA